

1501248-33.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Sandra Regina Nostre Marques

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... já decidido pelo E. STF: "Habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06).

Dosimetria. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (1.240 g de crack). Admissibilidade. Vetores a serem considerados necessariamente na dosimetria, nos termos do art. 59 do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

1ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1231 1501248-33.2021.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501248-33.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR LOPES DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

CONCLUSÃO:

Aos 06 de dezembro de 2021, faço os presentes autos conclusos a Exma.Sra. Dra.SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES, MMª. Juíza de Direito. Escr.:

Autos digitais controle nº 958/2021:

Vistos.

TIAGO DA SILVA NETO e VITOR LOPES DA SILVA, qualificados à fls. 14 e 18, respectivamente, foram denunciados pelo Ministério Público como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 22 de junho de 2021, por volta das 16h30, na Rua Vicente da Silva Moreira, 10, Centro, nesta cidade e Comarca, previamente ajustados, com unidade de desígnios e identidade de propósitos entre si, portavam e traziam consigo, para fins de venda, drogas, sendo 315 invólucros plásticos contendo 297,64 gramas de cocaína e 17 invólucros plásticos contendo 27,23 gramas de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl.08 e laudo de constatação de fls.10/12.

Segundo o apurado, nas condições acima mencionadas, os denunciados portavam e traziam consigo diversas porções de maconha e cocaína para realizar tráfico de drogas.

No dia dos fatos, policiais civis dirigiram-se ao local do ocorrido chamado "biqueira do DER", já conhecido ponto de traficância, e lá permaneceram em breve campana, observando que usuários se aproximavam do denunciado VÍTOR e, após breve diálogo, eram encaminhados ao denunciado TIAGO, o qual ficava alguns metros à frente. Em seguida, os usuários entregavam a TIAGO quantia em dinheiro e recebiam pequenos volumes.

Diante da fundada suspeita, os policiais abordaram os denunciados e durante revista pessoal foi localizada uma sacola próxima a TIAGO, na qual estavam as diversas porções de maconha e cocaína, além de uma pequena quantia em dinheiro.

Dada voz de prisão em flagrante, os denunciados foram conduzidos à delegacia de polícia.

A elevada quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das substâncias ilícitas apreendidas, divididas em porções individuais, prontas para venda, bem como as circunstâncias da prisão em flagrante dos denunciados, evidenciam que os entorpecentes se destinavam ao comércio ilícito de fls.4/70.

Foram arroladas pela acusação duas testemunhas que instruiu a denúncia com o inquérito policial de fls.4/70.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se encontra às fls. 57/60. Observo, porém, que em sede de HC, por liminar, foi concedida liberdade provisória ao réu Tiago (fls. 147/162).

Pela decisão de fls. 77/78 foi determinada a notificação dos denunciados, dentre outras providências.

Laudos foram juntados, a saber: fls. 13/15 (constatação provisória); fls. 103/104 e 105/106 (lesões corporais cautelares); e fls. 107/109 (exame químico toxicológico).

As folhas de antecedentes estaduais encontram-se juntadas a fls. 26/27 e 110/113 (Vítor), fls. 30 e 114/116 (Tiago). As folhas de antecedentes federais acham-se juntadas a fls. 146. Certidões SGCs acham-se juntadas a fls. 24 e 93 (Vítor) e fls. 28 e 92 (Tiago). As certidões da VIJ encontram-se juntadas a fls. 25 (Vítor); fls. 29 (Tiago).

O comprovante de depósito de valor apreendido acha-se juntado a fls. 131.

Regularmente notificado dos termos da inicial em 25.07.2021 (fl.143), o réu TIAGO ofertou defesa por meio de Defensor constituído (fls.132/136), acompanhada de documentos (fls.137/141). Regularmente notificado dos termos da inicial em 25.07.2021 (fl.145), o réu VÍTOR ofertou defesa por meio de Defensoria Pública nomeada (vide fl.178), sem arguir preliminares arrolando as mesmas testemunhas do rol acusatório (fls. 182).

A denúncia foi recebida pela decisão de fls.186/188 em 31.08.2021, designando-se audiência de instrução e julgamento.

Os réus foram pessoalmente citados a fls. 228 (Thiago) e fls. 230 (Vítor).

Realizada a audiência, foram inquiridas as testemunhas e interrogados os acusados por meio virtual. Na sequência, as partes debateram oralmente, tendo o Ministério Público sustentado pedido de condenação, enquanto as Defesas requereram a absolvição dos réus por insuficiência probatória, requerendo, outrossim, a aplicação de benefícios legais.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva evidencia-se pelo boletim de ocorrência de fls. 08/10, auto de exibição e apreensão de fls.11 (dinheiro e drogas), pela juntada do laudo de exame químico toxicológico de fls.107/109, que comprova que as substâncias eram maconha e cocaína.

A autoria, por outro lado, restou comprovada.

Os réus, ouvidos pela autoridade policial, reservam-se no direito de permanecer calados (vide fls. 17 - Tiago e fls. 21 - Vítor).

Em Juízo, o réu Tiago declarou que as drogas eram suas, afirmando que realmente

estava traficando, porém, atuava sozinho. Afirmou que o gerente do ponto foi quem lhe entregou as drogas, o qual atendia pela alcunha de "Lilico". Iria receber 10% (dez por cento) do produto das vendas. Vendeu apenas 100 (cem) reais naquele dia. Não conhecia o Vítor e disse que foi preso sozinho. Atualmente trabalha nos finais de semana em um restaurante, durante a semana trabalha em um lava rápido. Conheceu o gerente do tráfico no bairro DR aqui em São Bernardo do Campo. Quando menor de idade não teve envolvimento com a Justiça (gravação áudio visual no SAJ, fl.241). Em Juízo, o réu Vítor declarou que não estava traficando, sendo que passou no local dos fatos apenas para pegar um entorpecente. Disse que tinha acabado de sair do serviço, momento em que foi abordado pelos policiais. Afirmou que quem estava vendendo as drogas era o corréu Tiago, pessoa a quem não conhecia até então, sendo que não chegou a pegar o entorpecente que desejava comprar. Já tinha entregue o valor para Tiago e pretendia comprar duas porções. Negou que a sacola com as drogas lhe pertencessem. Disse que estava retornando do trabalho. Afirmou que trabalhava em uma obra e foi preso por volta de 16h30min. Já ficou internado na Fundação Casa por 3 meses na adolescência (gravação audiovisual no SAJ, fl.241).

Em que pesem as declarações dos réus, é certo que as provas os incriminam. A testemunha Thiago Lavorente de Paiva, policial civil, afirmou em Juízo que estava em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico, quando ingressaram com uma viatura descaracterizada e visualizaram duas vendas realizadas pelos réus. Vítor abordava o comprador e ia até o Thiago, o qual entregava entorpecente. Disse que fecharam as duas partes da viela, abordaram os dois e informalmente eles disseram que estavam vendendo as drogas, Vítor estava com os valores em dinheiro e Thiago estava com a sacola com as drogas (gravação audiovisual no SAJ, fl.241).

A testemunha David Oliveira de Medeiros, policial civil, afirmou em Juízo que estavam em operação no bairro do "DR", sendo que fizeram uma campana por cerca de 20 (vinte) minutos em viatura descaracterizada. Durante esse período, puderam observar que os usuários eram recepcionados pelo Vítor e posteriormente a droga era fornecida aos usuários por Thiago. A sacola com as drogas foi encontrada próximo de Thiago, sendo que com Vítor foi encontrado o dinheiro, mas não se lembra a quantia. Informalmente eles confessaram a traficância. Disseram que estavam ali desde de manhã. Sabe que o local era dominado pelo crime organizado. Não conhecia os réus anteriormente (gravação audiovisual no SAJ, fl.241).

A testemunha de Defesa Jairiana Maria Lopes disse que conhecia Thiago, porque ele trabalhava consigo no restaurante de sua propriedade, denominada "Casa do Norte Jade", o qual fica em São Bernardo do Campo. Disse que nada sabia dos fatos e nem tem conhecimento que ele fizesse tráfico de drogas, Afirmou que ele trabalhava consigo apenas nos finais de semana. Conhecia a mãe dele que frequentava o restaurante e nunca ouviu nenhum comentário ruim a respeito de Thiago (gravação audiovisual no SAJ, fl.241).

Como se vê da prova oral trazida aos autos, os relatos dos policiais são uníssonos e seguros em apontar que os acusados traziam consigo e guardavam as drogas apreendidas e que eram destinadas à comercialização espúria.

Em declarações convergentes, os policiais civis relataram que foram até o local, conhecido ponto de tráfico de drogas, com uma viatura descaracterizada e, durante breve campana puderam visualizar quando os usuários eram recepcionados por Vítor e a droga era fornecida por Thiago. Ademais, com eles, foram encontrados os entorpecentes descritos na denúncia (315 invólucros plásticos contendo 297,64 gramas de cocaína e 17 invólucros plásticos contendo 27,23 gramas de Maconha), além do dinheiro proveniente da venda espúria, sendo que informalmente confessaram aos policiais que estavam traficando.

Observo que a testemunha trazida pela defesa nada presenciou e, portanto, não trouxe aos autos nenhum elemento de prova e nem foi capaz de infirmar o quanto declararam os policiais.

E, ao contrário do sustentado pela Defesa, não há motivos para se desprezar as afirmações dos policiais. Eles não conheciam os acusados e, portanto, não havia motivos para que falsamente os acusassem.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que a condição de ser policial, por

si só, não justifica o afastamento de seus depoimentos. A esse propósito, o E. Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (RTJ 68/64).

Outrossim, acerca do assunto: “Inaceitável e preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (TACRIM/SP, 4º Grupo de Câmaras, Rel. Juiz LUIZ AMBRA, RT 732/632).

A Defesa, por sua vez, não trouxe aos autos nenhuma prova que infirmasse os depoimentos dos policiais. Se não bastassem os depoimentos dos policiais, o réu Vítor confessou que estava traficando, porém, sozinho.

Dessa forma, além dos depoimentos dos policiais e da confissão do réu Vítor, é certo que a variedade de drogas encontradas (maconha e cocaína) e a forma de acondicionamento (porções individuais), além do encontro de determinada quantia em dinheiro, não deixam dúvidas de que os réus traziam consigo e guardavam, com divisão de tarefas, as drogas mencionadas na denúncia, destinadas à comercialização e entrega a consumo de terceiros, conduta que vem a tipificar o crime definido no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, impondo lhes a sua condenação.

Dessa forma, passarei à dosagem de sua pena à luz do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Verificando as certidões de fls.93 (Vítor) e fls.92 (Thiago), observo que ambos os réus são tecnicamente primários. Contudo, Vítor ostenta condenação pelo mesmo crime, proferida poucos dias após sua prisão em flagrante pelo crime cometido nestes autos, como se verifica às fls.210/211 (autos nº 150.0693-50/2020, da 4ª Vara Criminal local) e quando se encontrava em liberdade provisória. Destaco que apesar de primários, hão de ser considerar as circunstâncias do delito, as quais envolvem quantidade expressiva de cocaína, o que autoriza a majoração da pena base, como já decidido pelo E. STF: “Habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06).

Dosimetria. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (1.240 g de crack). Admissibilidade. Vetores a serem considerados necessariamente na dosimetria, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. (...). É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes.(...)” (HC nº. 132.600/ES – Rel. Min. Dias Toffoli – Informativo 828). Assim, a grande quantidade de drogas apreendidas tem que ser considerada, eis que certamente causaria grande prejuízo para a Saúde Pública, bem jurídico tutelado. Dessa forma, para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do delito, fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa para cada um dos acusados.

Na segunda fase deve ser observada a atenuante da menoridade relativa para ambos os acusados, os quais contavam com menos de 21 anos na data dos fatos, de modo que diminuo a pena anteriormente fixada em 1/6 (um sexto), resultando em 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa para cada um dos réus. Quanto a atenuante da confissão realizada em Juízo por Thiago, esta não poderá ser reconhecida, haja vista que parcial, a medida que afirmou, ao contrário do que disseram os policiais, que estava traficando sozinho.

Neste sentido: “A confissão só pode ser reconhecida como atenuante obrigatória quando se dá de forma completa, a fim de se prestigiar a sinceridade do infrator, pois, em hipótese contrária, inexistente verdade total da dinâmica da ocorrência penal” (TACRSP,RJDTACRIM 31/84)

Impossível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº. 11.343/06, ao revés do quanto requer a Defesa. Isto porque o réu Vítor tem antecedente específico (vide fls. 210/211), as quais dão conta que o réu já foi condenado pela prática de idêntico delito, o que impede a concessão da benesse em tela. Vítor, ainda, como se observa, já se envolveu com a prática de inúmeros

delitos quando ainda adolescente (vide fls. 25), a indicar que se trata de pessoa que se dedica às atividades criminosas. O mesmo se diga em relação a Tiago, que admitiu que exercia o tráfico a mando de terceiro, evidenciando integrar organização criminosa. Além disso, em consonância com a situação erigida do caso concreto, já decidiu o E. TJSP que: “(...)Ora, todos sabem que para que se possa praticar qualquer das condutas previstas no caput do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06 não é suficiente a mera predisposição do agente para tanto. Não se consegue droga em grande quantidade, no atacado, em qualquer lugar. Não se pode efetuar a venda de entorpecentes em qualquer lugar, a menos que sob a autorização da organização criminosa que controla a atividade na região em que se pretende exercer o comércio ilícito. Caso contrário, sofrerá represálias. Notório que a atividade do tráfico de drogas assumiu características de negócio, sendo hoje principal fonte de renda de diversas fileiras do crime organizado. Assim, a prática de uma das condutas previstas no tipo penal do delito de tráfico de entorpecentes, no contexto apresentado nos autos é, em regra, parte de uma atividade empresarial (ilícita) estável e permanente, sendo claro que, os responsáveis pela organização da atividade, por certo, não confiariam a execução de uma das fases necessárias para a consecução do objetivo final da atividade a pessoa que não goze de sua confiança, ou seja, possua com eles estreito vínculo ou, ao menos, de alguma forma a justifique.(...)”. (TJSP - Apelação nº. 0001865-43.2016.8.26.0537 - Rel. Des. Euvaldo Chaib - 4ª Câmara de Direito Criminal - DJe: 09/05/2018).

Assim, torno definitivas as penas acima fixadas, ante a ausência de outras causas de aumento ou de diminuição.

Os réus não de iniciar o cumprimento de suas penas em regime fechado, haja vista que o crime aqui apurado é equiparado ao hediondo, nos termos do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90. Ainda nesta esteira, oportuna a transcrição do seguinte entendimento extraído do E. TJSP, concernente ao delito de tráfico de drogas:

“(...) apesar das circunstâncias pessoais do apelante lhe serem favoráveis, sua conduta de traficar drogas enseja especial censurabilidade pelos efeitos nefastos na saúde dos usuários e na Saúde Pública de um modo geral, além de servir de elemento propagador e incrementador de toda uma ordem criminosa, que tantos malefícios vem trazendo à nossa Sociedade. Ademais, volume de lucro fácil que já vinha experimentando está a vedar o regime aberto ou a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos, que não bastariam à reprovação do crime e não cumpririam a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. Não bastasse isto, impõe-se ao apelante, em observância ao princípio da constitucional da individualização da pena, uma resposta estatal adequada até mesmo para que se sinta desestimulado a prosseguir por este caminho abjeto, tudo em observância à função preventiva especial da pena.” (TJSP - Apelação nº. 0011363-29.2013.8.26.0066 - 2ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Alex Zilenovski - j. 29.08.2014).

Como se não bastasse, no caso concreto, os acusados foram surpreendidos na posse de grande quantidade de cocaína e maconha (auto de exibição e apreensão de fls.11 e laudo pericial de fls. 107/109). É certo que a natureza de tais substâncias entorpecentes impõe a fixação de regime rigoroso para o cumprimento da pena fixada. Em recente precedente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça proferiu o entendimento de que “imposição do regime inicial fechado e a negativa de substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos diante da “natureza altamente nociva de parte das substâncias entorpecentes negociadas - cocaína, substância causadora de efeitos extremamente deletérios (art. 42 da Lei nº 11.343/06) não denotam constrangimento ilegal”. (HC 335.839/SP - Sexta Turma - Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - DJe 19/02/2016). Igualmente: STF - Segunda Turma - HC nº. 103.141/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa - DJe: 10/02/2011.

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para:

A) condenar TIAGO DA SILVA NETO, RG nº 39.272.666, pela prática do crime definido no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, em regime inicial fechado;

B) condenar VITOR LOPES DA SILVA, RG nº 56.161.428, pela prática do crime definido no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a 5 (cinco) anos de reclusão e ao

pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, em regime inicial fechado.

Fixo a unidade da pena pecuniária, para cada um dos réus, na forma do artigo 43 da aludida Lei, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, valor que deverá ser corrigido desde o crime, quando da execução.

Os réus foram presos em flagrante como se verifica às fls.86/89, sendo Tiago beneficiado com a liberdade provisória. Vitor não faz jus a recorrer em liberdade, até porque ainda se acham presentes os motivos autorizadores de sua prisão preventiva. Destaco que há concretas possibilidades de novas incursões contra a ordem pública, aplicando-se, ainda, o entendimento, com relação ao tráfico de drogas, tal qual o aqui apurado, de que "(...) Crimes dessa natureza devem ser tratados com maior rigor, sobretudo por implicarem danos à ordem pública, haja vista a ocorrência de inúmeros delitos que decorrem, direta ou indiretamente, do tráfico de drogas. (...) " (TJSP 2ª Câmara de Direito Criminal HC 2089425-19.2014.8.26.0000 Rel. Des. Alex Zilenovski j.10.09.2014). Ademais, é de ressaltar que "(...) não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar" (STF HC 89824/MS Primeira Turma Rel. Min. Ayres Britto DJe: 28.08.2008). Observo que já se envolveu e foi condenado por idêntico delito em outra oportunidade (fls. 210/211). Recomende-se o acusado Vitor junto ao estabelecimento prisional em que se encontra, nos termos do § 1º do artigo 387 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, incabível a modificação do regime neste momento processual e aplicação de detração consoante o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, eis que não há condições de se aferir sua conduta carcerária, requisito subjetivo para a concessão de eventual progressão (artigo 112 do LEP). Além disso, não há certeza que a pena ora aplicada será a definitiva, eis que é passível, ainda, de recurso por parte do Ministério Público, o que poderá modificar o cálculo para a eventual progressão. Cabe à Vara das Execuções Penais averiguar a eventual aptidão para uma progressão, ainda, mais diante da notícia de que ainda há outra pena a ser cumprida.

Concedo a Tiago o direito de recorrer em liberdade, dada a decisão concedida em sede de habeas-corpus (fls. 147/162).

Já houve determinação para destruição das drogas (vide fls.57/60) Comunique-se à D. Autoridade Policial, se o caso.

Decreto a perda do dinheiro apreendido (fl.11) a favor da União, na forma do artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, devendo ser revertido ao FUNAD (artigo 63, § 1º, da Lei nº 11.343/06), eis que produto do ilícito.

Transitada em julgado a presente decisão, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados, expedindo-se, então, ofício ao SENAD informando do valor que foi declarado perdido a favor da União, nos termos do artigo 63, § 4º, da Lei nº 11.343/06, bem como mandado de prisão contra Tiago.

Arcarão os réus, na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, com o pagamento da taxa judiciária, bem como das despesas processuais, caso percam a condição de beneficiários da Justiça Gratuita (assistido pela Defensoria Pública atuante na Comarca e consoante declaração de fls. 138 - Tiago).

P.R.I.C.

São Bernardo do Campo, 23 de março de 2022.

SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA